

1502203-82.2021.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo de Azevedo Marchi

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... de majorar em 1/4 quando se tratar de tráfico de crack e em 1/6 quando se tratar de tráfico de cocaína, não merecendo majoração quando se tratar de tráfico de maconha. Assim, tendo em vista que as investigações demonstraram que o réu traficava cocaína, majoro a pena do acusado em 1/6).

Assim, fixo a pena base em 7/12 ($1/6 + 1/4 + 1/6 = 1/2$) acima do mínimo legal, ou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502203-82.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502203-82.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2302754/2021 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 21247751 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 3147/21/614 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 2302754 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Azevedo Marchi

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, ofereceu denúncia em face do réu PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA, como incurso no artigo 33, caput, e no artigo 34, ambos da Lei n.º 11.343/06 e artigo 180, caput, do Código Penal, todos na forma do artigo 69, do Código Penal.

Narrou a denúncia que, em data incerta, porém entre o dia 31 de maio de 2021 e o dia 07 de novembro de 2021, em Taboão da Serra/SP, o indiciado adquiriu e recebeu e, no dia 07 de novembro de 2021, por volta das 17h, na Rua Siderópolis, n.º 36, Jardim São Salvador, Taboão da Serra/SP, conduziu o veículo Nissan/March 16SL, ano 2015, modelo 2015, chassi 94DFCUK13FB502206, de placas FXD5022, de Taboão da Serra/SP, porém ostentando as placas FYX 1365, de propriedade de Fabiana Rodrigues

Silva, coisa que sabia ser produto de furto. Consta, ainda, que, no dia 07 de novembro de 2021, por volta das 17h00, na Rua Siderópolis, altura do n.º 36, Jardim São Salvador, Taboão da Serra/SP, o indiciado transportava, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes na massa líquida de, aproximadamente, 6,4kg (seis quilos e quatrocentos gramas) de cocaína, acondicionada em 07 (sete) invólucros plásticos, sendo esta substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta, por fim, que, no dia 07 de novembro de 2021, por volta das 17h00, na Rua Siderópolis, altura do n.º 36, Jardim São Salvador, Taboão da Serra/SP, o indiciado transportava objetos destinados à preparação e à transformação de drogas, consistentes em um liquidificador, duas balanças de precisão, um tambor e uma máquina para embalagem à vácuo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 86/89). Notificado (fls. 109/110), o réu constituiu defensor (procuração à fl. 58), que apresentou defesa preliminar às fls. 98/99.

A denúncia foi recebida no dia 30 de maio de 2022 (fls. 114/117).

O réu foi citado (fls. 198/200).

Designada a audiência de instrução e julgamento, a denúncia foi aditada sem oposição da defesa para corrigir a quantidade de droga atribuída ao acusado.

Em seguida, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público postulou a procedência do pedido contido na denúncia com a condenação do acusado.

A Defesa advogou teses benéficas ao réu.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito de fl. 01; boletim de ocorrência de fls. 02/07; auto de exibição e apreensão de fls. 13/15; fotografia (fls. 16/17); auto de constatação de fls. 18/21 e 132/134; auto de depósito (fl. 23); boletim de ocorrência atinente ao furto (fls. 34/35); laudo definitivo de fls. 135/137; laudo da máquina seladora (fls. 138/140); laudo IC objeto (celular - 141/146); laudo IC objeto (balança, fls. 147/149 e 150/152); laudo IC objeto (garrafa plástica com líquido amarelado, fls. 153/157); laudo IC objeto (base de liquidificador, fls. 158/159); laudo IC objeto (diversos objetos, fls. 160/165); laudo IC objeto (tambor, fls. 166/168); bem como pelos depoimentos colhidos durante a fase policial e instrução judicial.

A autoria também é certa e recai sobre a pessoa do acusado.

Extrajudicialmente, o policial militar, Wagner Nogueira dos Santos, declarou: "Que exerce a função de comandante de equipe junto a Companhia de Força Tática do 36ºBPM/M, onde o policial militar Moreira é integrante sendo que, ambos se utilizam da viatura M36015. Que encontravam-se em patrulhamento quando, por volta das 17:00h do dia de hoje, pela Rua Sideirópolis se depararam com o veículo NISSAN MARCH, cor branca, ostentando placas FYX 1365. Que, quando o condutor do referido veículo viu a viatura ficou visivelmente nervoso. Que, para verificar qual o motivo da atitude não natural de tal condutor, os policiais em tela deram ordem sonora de parada sendo, de pronto, obedecidos. Que, o condutor do veículo trata-se do ora indiciado Paulo Henrique de Oliveira Souza. Que, já na revista realizada no veículo, em seu porta malas, foram encontradas duas balanças, um liquidificador, uma prensa de embalagens, uma forma em forma retangular e sete embalagens contendo pó branco, todas dentro de um balde azul de material plástico. Que questionado, Paulo disse que teria negociado tal material para "tentar levantar uma grana" e que teria pago cerca de três mil reais pelo referido material. Que, sendo verificado o chassi do mencionado veículo, constatou-se tratar-se do chassi 94DFCUK13FB502206, que pertence ao veículo placas FXD 5022, para o qual consta queixa de furto. Que, sobre o veículo, Paulo Henrique, disse que o comprou na "Feira do rolo" do Facebook, pelo valor de mil reais e que o vendedor havia lhe informado que tratava-se de um veículo clonado e que havia, também o vendedor, trocado as placas originais. Que, durante a abordagem, os pais de Paulo se fizeram presentes no local e foram informados que, Paulo Henrique, seria conduzido até esta distrital." (fl. 08). Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos. Acrescentou que a

quantidade droga era substancial. Não se recordou o peso exato.

Na fase inquisitiva, o policial militar, Henrique Augusto Costa Moreira, declarou: "Que exerce a função de integrante de equipe junto a Companhia de Força Tática do 36º BPM/M, onde o Sargento Nogueira é comandante da referida equipe sendo que ambos se utilizam da viatura M36015. Que encontravam-se em patrulhamento quando, por volta das 17:00h do dia de hoje, pela Rua Sideirópolis se depararam com o veículo NISSAN MARCH, cor branca, ostentando placas FYX 1365. Que, quando o condutor do referido veículo viu a viatura ficou visivelmente nervoso. Que, para verificar qual o motivo da atitude não natural de tal condutor, os policiais em tela deram ordem sonora de parada sendo, de pronto, obedecidos. Que, o condutor do veículo trata-se do ora indiciado Paulo Henrique de Oliveira Souza. Que, já na revista realizada no veículo, em seu porta malas, foram encontradas duas balanças, um liquidificador, uma prensa de embalagens, uma forma em forma retangular e sete embalagens contendo pó branco, todas dentro de um balde azul de material plástico. Que questionado, Paulo disse que teria negociado tal material para "tentar levantar uma grana" e que teria pago cerca de três mil reais pelo referido material. Que, sendo verificado o chassi do mencionado veículo, constatou-se tratar-se do chassi 94DFCUK13FB502206, que pertence ao veículo placas FXD 5022, para o qual consta queixa de furto. Que, sobre o veículo, Paulo Henrique, disse que o comprou na "Feira do rolo" do Facebook, pelo valor de mil reais e que o vendedor havia lhe informado que tratava-se de um veículo clonado e que havia, também o vendedor, trocado as placas originais. Que, durante a abordagem, os pais de Paulo se fizeram presentes no local e foram informados que, Paulo Henrique, seria conduzido até esta distrital." (fl. 09).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos. Acrescentou que a quantidade de droga era muito superior ao que comumente costuma apreender. Interrogado em solo policial, o indiciado, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA, declarou: "Que possui advogado na pessoa do Dr. Josué Antônio de Souza - presente neste ato. Que não possui antecedentes criminais. Que não é casado. Que não possui filhos. Que não é portador de doença grave. Que trabalha no bar do pai e, por vezes trabalha fazendo entregas, com motociclo, para um aplicativo. Que em relação ao veículo NISSAN MARCH, cor branca, que ostenta placas FYX 1365, o comprou há menos de vinte dias na "Feira do rolo" do Facebook. Que pelo veículo pagou a quantia de um mil reais. Que não se recorda do nome do vendedor. Que pegou o carro próximo à Praça do Taboão. Que o vendedor disse que o veículo era 'b.o.', mas que já havia trocado as placas e que depois iria entregar o respectivo documento. Que comprou o veículo para fazer entregas por aplicativo. Que em relação às balanças, demais objetos e o pó branco encontrados no interior do veículo, são eles de um amigo do ora indiciado de prenome João, cujos demais dados e endereço desconhece. Que, quando João soube que o ora indiciado havia comprado o veículo em tela, pediu para guardar tais produtos no veículo, o que foi aceito pelo ora indiciado. Que faz dois ou três dias que João guardou as embalagens de pó branco e os objetos apreendidos no veículo do ora indiciado dizendo que tratavam-se de equipamentos e produtos que utilizava em sua função de pintor. Que, pouco depois das 17:00h, estava conduzindo o veículo ora apreendido quando, ao passar pela Rua Sideirópolis, neste Município de Taboão da Serra, foi abordado por policiais militares que, ao revistarem o veículo, encontraram os itens mencionados os quais estavam no porta malas no referido veículo NISSAN. Que não entende sobre drogas, não sabendo dizer o que seriam as embalagens de pó branco referidas e não conferiu o que João havia guardado em seu veículo pois, como disse, tal pessoa havia informado tratar-se de equipamentos destinados à pintura. Que nunca aceitaria coisas ilícitas em seu veículo. Que não sabe precisar se, o que foi encontrado em seu veículo sejam drogas. Que, pelo que sabe dizer, João trabalha com pinturas. Que não sofreu agressões por parte dos policiais. Que, a mesma versão que disse neste ato, disse aos policiais militares." (fls. 10/11).

Em juízo, o acusado negou a prática do crime de tráfico de drogas. Disse que estava apenas com seis cápsulas de cocaína que eram para o seu uso pessoal. Sobre o restante das drogas disse que emprestou o carro para um amigo chamado João dois

dias antes de ser preso. Ele que deixou a droga no carro. Ele falou que deixaria materiais de pintura no carro, não disse que eram drogas. O acusado não conferiu o material. Não sabe o nome completo dele e ele mora na Rua Siderópolis mas não sabe o número dele. Seu pai foi até a casa dele mas disse que não o achou. O carro comprou na feira do rolo do facebook. O vendedor disse que o acusado poderia trabalhar com ele. O vendedor não disse que era produto de crime, disse apenas que tinha problema no documento. O vendedor chama Guilherme Souza. Não sabe mais nenhum outro dado dele. Não tem passagens. Quando era menor de idade foi condenado duas vezes por roubo. Sabia que o veículo era produto de crime anterior.

Como se denota, à luz do arcabouço probatório constante dos autos, verifico que a condenação do réu pelos crimes de tráfico de drogas e receptação é medida de rigor. Com efeito, os depoimentos prestados pelas testemunhas foram uníssonos e harmônicos no sentido que o acusado trazia consigo para fins de entrega a consumo de terceiros drogas em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como que o veículo em que trafegava era produto de crime anterior.

Ademais, não se deve ignorar que a grande quantidade de droga encontrada é prova que indica que o réu a detinha com o fim de revendê-la a terceiros.

Nesse particular, é importante registrar que contém erro material no auto de exibição e apreensão de fls. 13/15 onde constou que foram apreendidas 6,4g de cocaína, uma vez que a fotografia de fls. 16 já demonstrava que a quantidade apreendida era bem superior.

Além disso, tanto o laudo de constatação de fls. 18/21 como o laudo pericial de fls. 135/137 comprovaram que a quantia correta apreendida e periciada era a de 6,4kg, confirmando os depoimentos prestados pelos policiais no sentido de que encontraram com o acusado abundante quantidade de cocaína.

Urge mencionar que os depoimentos prestados pelos agentes públicos, subordinados às regras de processo penal e de direito administrativo, gozam de credibilidade e da presunção de veracidade, uma vez que prestam testemunho de forma compromissada e sob as penas da lei. Não havendo razões outras que indiquem a falta de compromisso com a verdade, a simples função por eles exercida não é de molde a ensejar o descrédito das declarações prestadas.

Nesse sentido:

"(...)Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. (...)" (HC 204.733/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 25/08/2011)

"(...) 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (...)" (STJ Min. Laurita Vaz 5ª Turma HC nº 115516/SP 03/02/2009)

No caso em testilha, nada justifica o desmerecimento da versão apresentada pelos policiais, harmônica com os demais elementos probatórios colacionados, especialmente porque o transporte da droga não foi contestada pelo próprio acusado. A versão trazida pelo acusado de que não tinha conhecimento da droga encontrada em seu veículo é inverossímil uma vez que não produziu nenhuma prova nesse sentido, não tendo nem mesmo qualificado corretamente a suposta pessoa para quem teria emprestado seu veículo e que teria deixado os entorpecentes no seu interior.

Por outro lado, imperioso reconhecer que entre os crimes do artigo 33 e 34, ambos da Lei nº 11.343/2006, há nítida relação de consunção, respondendo o réu apenas pelo primeiro tipo penal.

De fato, o tipo penal do artigo 34, da Lei nº 11.343/2006 visa proteger a saúde pública, ameaçada com a possibilidade de a droga ser produzida, ou seja, tipifica-se conduta que pode ser considerada como mero ato preparatório.

Desta feita, a prática do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 absorve o delito capitulado no artigo 34 da mesma lei.

Nada obstante, ressalta-se que a referida absorção somente será viável desde que não fique caracterizada a existência de contextos autônomos e coexistentes, aptos a

vulnerar o bem jurídico tutelado de forma distinta

Nesse sentido:

"(...) ABSORÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NO § 1º DO ARTIGO 33 E NO ARTIGO 34 PELO DO CAPUT DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1. Esta Corte Superior de Justiça entende que é possível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes previstos no § 1º do artigo 33 e no artigo 34 pelo tipificado no caput do artigo 33 da Lei 11.343/2006, desde que não caracterizada a existência de contextos autônomos e coexistentes, aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado de forma distinta. 2. No caso dos autos, a autoridade apontada como coatora reconheceu que as infrações penais em apreço teriam sido práticas em contextos fáticos distintos, não havendo que se falar, assim, em aplicação do princípio da consunção. 3. Para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória providência incompatível com o rito célere do habeas corpus. Precedente. (...) (STJ - HC 346077 / SP; QUINTA TURMA; Rel. Ministro JORGE MUSSI; j. 17/05/2016)

"DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. 1. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MAQUINÁRIO. ASSOCIAÇÃO. ARTS. 33, 34 E 35 DA LEI N. 11.343/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DECOTE DE CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. INCIDÊNCIA DE REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA MESMA LEI. PLEITOS INVIÁVEIS NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS NORMAS VIOLADAS. RECURSO ESPECIAL COM MOTIVAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 2. PEDIDOS QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPROPRIEDADE DA PROVIDÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. 3. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA NOS ARTS. 33 E 34 DA LEI N. 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. POSSE E INSTRUMENTOS. CRIME MEIO. 4. BALANÇA DE PRECISÃO E SERRA CIRCULAR. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE. OBJETOS PRÓPRIOS DO CRIME DE TRÁFICO. 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. (...) 3. Há nítida relação de subsidiariedade entre os tipos penais descritos nos arts. 33 e 34 da Lei 11.343/2006. De fato, o tráfico de maquinário visa proteger a "saúde pública, ameaçada com a possibilidade de a droga ser produzida", ou seja, tipifica-se conduta que pode ser considerada como mero ato preparatório. Portanto, a prática do art. 33, caput, da Lei de Drogas absorve o delito capitulado no art. 34 da mesma lei, desde que não fique caracterizada a existência de contextos autônomos e coexistentes, aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado de forma distinta. No caso, referida análise prescinde do reexame de fatos, pois da leitura da peça acusatória, verifica-se que a droga e os instrumentos foram apreendidos no mesmo local e num mesmo contexto, servindo a balança de precisão e a serra/alicate de unha à associação que se destinava ao tráfico de drogas, não havendo a autonomia necessária a embasar a condenação em ambos os tipos penais simultaneamente, sob pena de bis in idem. 4. Salutar aferir, ademais, quais objetos se mostram aptos a preencher a tipicidade penal do tipo do art. 34 da Lei de Drogas, o qual visa coibir a produção de drogas. A meu ver, deve ficar demonstrada a real lesividade dos objetos tidos como instrumentos destinados à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sob pena de a posse de uma tampa de caneta - utilizada como medidor -, atrair a incidência do tipo penal em exame. Relevante, assim, analisar se os objetos apreendidos são aptos a vulnerar o tipo penal em tela. No caso dos autos, além de a conduta não se mostrar autônoma, verifico que a apreensão de uma balança de precisão e de um alicate de unha não pode ser considerada como posse de maquinário nos termos do que descreve o art. 34 da Lei de Drogas, pois referidos instrumentos integram a prática do delito de tráfico, não se prestando à configuração do crime de posse de maquinário. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para excluir a condenação dos recorrentes Márcia Regina Millezi e Francisco Luís Alves de Lima pela prática do delito do art. 34 da Lei de Drogas." (STJ - REsp 1196334 / PR; QUINTA TURMA; Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE; j. 19/09/2013)

Ocorre que no caso em apreço as drogas e os petrechos foram flagrados dentro do veículo conduzido pelo réu no mesmo contexto factual, implicando a absorção do tipo penal previsto no art. 34 pelo capitulado no art. 33 da Lei de Drogas. Por outro lado, diante do arcabouço probatório constante dos autos, verifico que a

condenação do réu pelo crime de receptação imputado na denúncia é medida de rigor, notadamente pelas declarações dos agentes públicos e das testemunhas, quanto à origem ilícita do bem apreendido.

Provado que o acusado adquiriu e conduziu veículo produto de furto, preencheu todos os requisitos descritos no tipo penal, capitulado no art. 180 do Código Penal, de forma que caberia ao acusado comprovar de que não tinha conhecimento da origem espúria do bem, ônus do qual não se desincumbira, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"

(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018). (AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020)

Ainda que assim não fosse, ao final do interrogatório judicial o acusado acabou admitindo que tinha ciência da origem ilícita do veículo, confessando a prática criminosa.

Portanto, demonstradas a autoria e materialidade dos delitos, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o agente de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória em relação aos crimes de tráfico de drogas e receptação.

Passo a dosar as reprimendas.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (nada a considerar, o réu é primário e não ostenta maus antecedentes, é o que se deduz da Folha de Antecedentes de fls. 50/51 e da Certidão de Distribuição de Eventos de fls. 169/170); conduta social (nada a ser valorado); personalidade (não há elementos para aferir eventual personalidade nociva do réu); motivos do crime (inerentes à espécie); circunstâncias do crime (tendo em vista que além das drogas no mesmo contexto foram encontrados com o acusado petrechos para preparação do entorpecente, tais como balança, liquidificador, seladora e invólucro plástico, aumento a pena em 1/6); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (nada a considerar); quantidade da droga (o réu foi surpreendido transportando elevada quantidade de droga, correspondente a 6,4kg de cocaína, especialmente considerando que cada porção individual de cocaína tem aproximadamente 1g de forma que o total de droga apreendida com o acusado possibilitaria a produção de aproximadamente 6.400 porções individuais, exigindo o aumento de pena em 1/4); natureza da droga (considerando que numa escala de ofensividade à saúde o crack está à frente da cocaína que, por sua vez, está à frente da maconha, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, verifico a necessidade de majorar em 1/4 quando se tratar de tráfico de crack e em 1/6 quando se tratar de tráfico de cocaína, não merecendo majoração quando se tratar de tráfico de maconha. Assim, tendo em vista que as investigações demonstraram que o réu traficava cocaína, majoro a pena do acusado em 1/6).

Assim, fixo a pena base em 7/12 ($1/6 + 1/4 + 1/6 = 1/2$) acima do mínimo legal, ou seja, 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não verifico a presença de circunstâncias agravantes.

Porém incide a atenuante da menoridade relativa, visto que o réu era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, que valoro em 1/6, totalizando 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 659 (seiscentos e cinquenta e nove) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não estão presentes causas de aumento ou diminuição

de pena.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Isso porque, embora o acusado seja primário, não tenha maus antecedentes e não existam provas de que faça parte de organização criminosa, verifico que se dedicava à atividade criminosa.

Nesse diapasão, imperioso ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido, por ambas as Turmas, que a existência de registros por atos infracionais é elemento hábil a evidenciar a dedicação do agente a atividades delituosas e, por conseguinte, a impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Nesse sentido:

"(...) 2. A causa redutora de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei n. 11.343/06 poderá ser aplicada quando cumpridos os seguintes requisitos: ser primário, possuir bons antecedentes, não dedicar-se a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. Na hipótese dos autos, verifica-se que o Magistrado sentenciante destacou que o paciente, embora não possua condenação definitiva, não possui bons antecedentes, pois, quando menor de idade, respondeu a diversos atos infracionais, todos por tráfico de drogas, o que demonstra que possui vida pregressa de dedicação à atividade criminosa. Dessa forma, verifico que não há ilegalidade na vedação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, haja vista que as instâncias ordinárias fundamentaram concretamente a negativa da benesse, vedada em razão da dedicação do paciente à atividade criminosa. Precedentes. Ademais, para se acolher a tese de que a paciente não se dedica às atividades criminosas, é necessário o reexame aprofundado das provas, inviável em habeas corpus. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 431.001/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 23/3/2018).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS.

1. A existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais.

Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.

(AgInt no HC n. 467.947/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 1º/2/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRIVILÉGIO PREVISTO NO § 4º DA LEI N. 11.342/2006. IMPOSSIBILIDADE. ANOTAÇÃO DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o ato infracional praticado pode ser considerado como elemento de convicção de que o agente se dedicava às práticas delituosas. II - In casu, o recorrente possui anotação pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, o que foi utilizado de maneira fundamentada pelo eg. tribunal a quo para não conceder a benesse do privilégio previsto no § 4º do art. 33, da Lei 11.344/2006, já que ficou demonstrado a dedicação às práticas delituosas do agente. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.630.635/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 23/06/2020).

"(...)6. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes.

(AgRg no HC n. 635.905/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 19/3/2021).

"(...) III - In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na quantidade e na natureza da droga apreendida, ou seja: 5,71 g de cocaína e 10,10 g de maconha. De mais a mais, "a Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes" (AgRg no HC n. 546.316/SP, Sexta

Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 13/10/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRIVILÉGIO PREVISTO NO § 4º DA LEI N. 11.342/2006. IMPOSSIBILIDADE. ANOTAÇÃO DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o ato infracional praticado pode ser considerado como elemento de convicção de que o agente se dedicava à práticas delituosas. II - In casu, o recorrente possui anotação pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, o que foi utilizado de maneira fundamentada pelo eg. tribunal a quo para não conceder a benesse do privilégio previsto no § 4º do art. 33, da Lei 11.344/2006, já que ficou demonstrado a dedicação à práticas delituosas do agente.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.918.565/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/3/2021).

Assim, tendo em vista os antecedentes infracionais do acusado registrados às fls. 53, verifico que o réu se dedicava à atividade criminosa, fazendo dela seu meio de vida, o que impede a concessão do benefício.

Como se não bastasse, o acusado foi preso transportando expressiva quantidade de cocaína (6,4kg) dentro de um carro produto de crime anterior o que, de acordo com a jurisprudência do STJ, obsta a aplicação do redutor.

Nesse sentido, observa-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a circulação de expressiva quantidade de entorpecente pelo agente evidencia sua habitualidade delitiva, autorizando o afastamento do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Nesse sentido:

"(...) Esta Corte tem entendimento firme de que é possível a aferição da quantidade e da natureza da substância entorpecente, concomitantemente, na primeira etapa da dosimetria, para exasperar a pena-base e, na terceira, para justificar o afastamento da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 - quando evidenciado o envolvimento habitual do agente no comércio ilícito de entorpecentes - sendo tal hipótese distinta da julgada, em repercussão geral, pela Suprema Corte no ARE 666.334/AM. (...) (STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 549.034/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 09/06/2020 - tese 46).

Ainda, no REsp nº 1.773.834, por unanimidade de votos decidiu "que a elevada quantidade de drogas apreendidas pode ser perfeitamente sopesada para aferir o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação a atividades delituosas, comportando, todavia, prova em sentido contrário."

Assim, fixo definitivamente a pena do acusado em 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 659 (seiscentos e cinquenta e nove) dias-multa.

Quanto ao crime de receptação, na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (dolo inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (antecedentes (nada a considerar, o réu é primário e não ostenta maus antecedentes, é o que se dessume da Folha de Antecedentes de fls. 50/51 e da Certidão de Distribuição de Eventos de fls. 169/170); conduta social (nada a considerar); personalidade (normal à espécie); motivos do crime (inerente ao tipo penal); circunstâncias do crime (tendo em vista que o acusado adquiriu e conduziu veículo produto de crime anterior com as placas alteradas a fim de impedir ou dificultar a vigilância policial e assegurar o proveito criminoso, verifico que o crime de receptação praticado pelo acusado no caso concreto foi mais grave que o habitual, devendo a pena ser aumentada em 1/6); consequências do crime (nada a considerar); comportamento da vítima (nada a considerar).

Assim, fixo a pena base 1/6 no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não verifico a presença de circunstâncias agravantes.

Presentes as atenuantes da menoridade relativa, visto que o réu era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, bem como a circunstância atenuante da confissão, previstas

no art. 65, incisos I e III, alínea "d", do Código Penal, reduzo a pena ao patamar mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, isto é, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, estão ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, assim, fixo a pena definitiva do réu em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando que os crimes foram praticados em concurso material de crime, nos termos do art. 69 do Código Penal, somo as penas aplicadas, alcançando um patamar de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 669 (seiscentos e sessenta e nove) dias-multa.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena nos termos do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 c/c art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal c/c o artigo 42, da Lei 11.343/06, considerando se tratar de crime equiparado a hediondo, o passado infracional do acusado, a grande quantidade de cocaína apreendida, bem como a prática de dois crimes pelo acusado, que exigem a fixação do regime mais rigoroso para uma correta prevenção criminal.

Em que pese a resolução nº 5 do Senado Federal, verifico que não se fazem presentes os requisitos descritos no artigo 44 do Código Penal em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada supera os quatro anos.

Também não é cabível o benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, CP). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido da ação penal e assim o faço para:

CONDENAR o réu PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 669 (seiscentos e sessenta e nove) dias-multa, fixados estes em 1/30 do salário mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e artigo 180, caput, do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do Código Penal;

ABSOLVER o réu PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA pela prática do crime capitulado no art. 34, caput, da Lei nº 11.343/06 nos termos do art. 386, inc. I, do Código de Processo Penal.

Estando presentes os requisitos e fundamentos que levaram à prisão preventiva do acusado, agora reforçados pela certeza acerca da materialidade e autoria, conforme fundamentado acima, INDEFIRO o direito do réu de recorrer em liberdade.

Expeça-se guia de execução provisória.

Transitado em julgado: a) expeçam-se guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.

Custas ex legis.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.